EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF

DD. CÁRMEN LÚCIA

**"**Onde quer que haja um direito individual violado, há de haver um recurso judicial para a debelação da injustiça, este é o princípio fundamental de todas as constituições livres" **(Rui Barbosa)**

*"Uma Constituição escrita não configura mera peça jurídica, nem é simples estrutura de normatividade e nem pode caracterizar um irrelevante acidente histórico na vida dos povos e das nações. Todos os atos estatais que repugnem à Constituição expõem-se à censura jurídica – dos tribunais, especialmente – porque são írritos, nulos e desvestidos de qualquer validade. A Constituição não pode submeter-se à vontade dos poderes constituídos e nem ao império dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de que ela se reveste – enquanto for respeitada – constituirá a garantia mais efetiva de que os direitos e as liberdades não serão jamais ofendidos*" (ADIn 293-7/DF – Rel. Ministro Celso de Mello – Decisão liminar – DJU de 16.04.1993 – p. 6429).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI.
(*DEVENDO À LUZ DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, SE FOR O CASO, SER RECEBIDA COMO AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - ADPF*)

O PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT, partido político com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral - TSE (Resolução nº 11.165, de 11 de junho de 1982), com endereço declinado na procuração que acompanha a presente, vem, por seus advogados firmatários (doc. 1), propor, com amparo nos artigos 102, inciso I, alínea "a" e 103, inciso VIII, ambos da Constituição Federal e forte no que estatui a Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

c/c pedido de liminar

Em face do inteiro teor do Decreto autônomo nº 9.188, de 1º de novembro de 2017, que *estabelece regras de governança, transparência e boas práticas de mercado para a adoção de regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mistas federais*.

I – Do dispositivo "legal" inquinado de Inconstitucionalidade.

O Senhor Presidente da República, juntamente com o Ministro do Planejamento, Orçamento de Gestão, editou e fez publicar no Diário Oficial da União de 1º de novembro de 2017, o Decreto nº 9.188, que *estabelece regras de governança, transparência e boas práticas de mercado para a adoção de regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais*.

O referido Decreto, conquanto tenha a pretensão inicial regulamentadora, invade de forma escancarada competências reservadas à lei e à própria Constituição Federal, de modo que vem ao mundo jurídico com natureza eminentemente autônoma e eivado de inconstitucionalidades.

O Supremo Tribunal Federal já se posicionou em diversas oportunidades acerca do cabimento do controle concentrado em face de Decreto de natureza autônoma, editado em contrariedade direta ao texto constitucional.

Nesse sentido:

> "No caso, porém, a Lei 11.580, de 14-11-1996, que dispõe sobre o ICMS, no Estado do Paraná, conferiu certa autonomia ao Poder Executivo, para conceder imunidades, não incidências e benefícios fiscais, ressalvando, apenas, a observância das normas da Constituição e da legislação complementar. Assim, o Decreto 2.736, de 5-12-1996, o Regulamento do ICMS, no Estado do Paraná, ao menos nesses pontos, não é meramente regulamentar, pois, no campo referido, desfruta de certa autonomia, uma vez observadas as normas constitucionais e

> complementares. Em situações como essa, o Plenário do STF, ainda que sem enfrentar, expressamente, a questão, tem, implicitamente, admitido a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, para impugnação de normas de decretos." (ADI 2.155-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 15-2-2001, Plenário, DJ de 1º-6-2001.) No mesmo sentido: ADI 4.152, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 1º-6-2011, Plenário, DJE de 21- 9-2011. (g.n).

O Decreto nº 9.188, de 2017 configura decreto executivo autônomo, passível de controle abstrato de constitucionalidade, conforme a lição de Uadi Lammêgo Bulos:

> [...] se o decreto ou o ato regulamentar for autônomo será possível o controle concentrado, via ação direta de inconstitucionalidade, para verificar se houve ofensa ao princípio constitucional da reserva legal ou, até mesmo, invasão de competência [...] (Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 173, destaque no original).

Ainda:

> "Estão sujeitos ao controle de constitucionalidade concentrado os atos normativos, expressões da função normativa, cujas espécies compreendem a função regulamentar (do Executivo), a função regimental (do Judiciário) e a função legislativa (do Legislativo). Os decretos que veiculam ato normativo também devem sujeitar-se ao controle de constitucionalidade [...]" (ADI-AgR n. 2.950/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Eros Grau, DJU de 9-2-2007).

Como se verá ao longo da presente exordial, o Decreto aqui hostilizado, embora formalmente tenha vindo ao mundo jurídico com o viés regulamentador, do ponto de vista material, substancial, pronuncia-se sobre diversas matérias reservadas à lei e, o que é mais grave, se volta diretamente contra diversos dispositivos constitucionais, de modo que se justifica, plenamente, a propositura desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

A norma autônoma impugnada tem o seguinte conteúdo:

> *DECRETO Nº 9.188, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2017*
>
> *Estabelece regras de governança, transparência e boas práticas de mercado para a adoção de regime especial de desinvestimento de ativos pelas*

*sociedades de economia mista federais.*

***O PRESIDENTE DA REPÚBLICA**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, **caput**, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 28, § 3º, inciso II, e § 4º, e no art. 29, **caput**, inciso XVIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016,*

***DECRETA:***

*CAPÍTULO I*

*DO REGIME ESPECIAL DE DESINVESTIMENTO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA*

*Art. 1º Fica estabelecido, com base na dispensa de licitação prevista no art. 29, caput, inciso XVIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e no âmbito da administração pública federal, o regime especial de desinvestimento de ativos das sociedades de economia mista, com a finalidade de disciplinar a alienação de ativos pertencentes àquelas entidades, nos termos deste Decreto.*

*§ 1º As disposições previstas neste Decreto aplicam-se às sociedades subsidiárias e controladas de sociedades de economia mista.*

*§ 2º As disposições previstas neste Decreto não se aplicam às hipóteses em que a alienação de ativos esteja relacionada aos objetos sociais das entidades previstas no caput e no § 1º, às empresas de participação controladas pelas instituições financeiras públicas e aos bancos de investimentos, que continuarão sendo regidos pelo disposto no art. 28, § 3º, inciso I, da Lei nº 13.303, de 2016.*

*§ 3º O regime de que trata o caput poderá abranger a alienação parcial ou total de ativos.*

*§ 4º Para os fins do disposto neste Decreto, consideram-se:*

*I - ativos - as unidades operacionais e os estabelecimentos integrantes do seu patrimônio, os direitos e as participações, diretas ou indiretas, em outras sociedades; e*

*II - alienação - qualquer forma de transferência total ou parcial de ativos para terceiros.*

*§ 5º O disposto neste Decreto não se aplica às operações de alienação entre a sociedade de economia mista e as suas subsidiárias e controladas e às operações entre as subsidiárias e as controladas.*

*Art. 2º O regime especial de desinvestimento de ativos previsto neste Decreto tem os seguintes objetivos:*

*I - incentivar a adoção de métodos de governança corporativa que assegurem a realização do objeto social pela sociedade de economia mista;*

*II - conferir transparência e impessoalidade aos processos de alienação;*

*III - garantir segurança jurídica aos processos de alienação por meio da observância da legislação e das demais normas aplicáveis;*

*IV - permitir a fiscalização, nos termos da legislação;*

*V - garantir a qualidade e a probidade do processo decisório que determina o desinvestimento;*

*VI - permitir a obtenção do maior retorno econômico à sociedade de economia mista e a formação de parcerias estratégicas;*

*VII - estimular a eficiência, a produtividade e o planejamento de longo prazo das atividades e dos negócios afetos à sociedade de economia mista;*

*VIII - aproximar as sociedades de economia mista das melhores práticas de governança e gestão reconhecidas pelo setor privado;*

*IX - proporcionar ambiente de previsibilidade e racionalidade para a tomada de decisão pelos agentes envolvidos no setor; e*

*X - garantir a sustentabilidade econômica e financeira da sociedade de economia mista.*

*Art. 3º A Diretoria-Executiva das sociedades de economia mista poderá elaborar e propor programa de desinvestimento de ativos, o qual indicará, no mínimo:*

*I - os segmentos de negócio nos quais o desinvestimento será concentrado;*

*II - os objetivos e as metas a serem alcançados;*

*III - a compatibilidade da medida com o interesse da sociedade de economia mista;*

*IV - a conveniência e a oportunidade na alienação, considerados o plano estratégico, o plano de negócios, o plano plurianual ou instrumentos similares;*

*V - as perspectivas e as premissas macroeconômicas envolvidas; e*

*VI - o procedimento específico interno de apoio ao desinvestimento.*

*§ 1º A adesão da sociedade de economia mista ao regime especial de desinvestimento de ativos previsto neste Decreto será facultativa e dependerá de aprovação do Conselho de Administração ou do órgão diretivo máximo e de comunicação ao Ministério supervisor.*

*§ 2º Sem prejuízo da aprovação do Conselho de Administração ou do órgão diretivo máximo, caberá aos órgãos estatutários competentes a aprovação de cada alienação prevista no programa de desinvestimento.*

*§ 3º As subsidiárias e as controladas da sociedade de economia mista deverão comunicá-la sobre os desinvestimentos realizados.*

*§ 4º As subsidiárias e as controladas poderão conduzir seus desinvestimentos por meio de compartilhamento de políticas, estruturas, custos e mecanismos de divulgação com sua controladora.*

*Art. 4º A sociedade de economia mista, no prazo de trinta dias, contado da data de assinatura dos instrumentos jurídicos negociais de cada alienação, encaminhará cópias desses documentos para ciência do Tribunal de Contas da União.*

*Parágrafo único. Os instrumentos jurídicos negociais firmados no processo de alienação serão regidos pelos preceitos de direito privado.*

## *CAPÍTULO II*

## *DO PROCEDIMENTO COMPETITIVO DE ALIENAÇÃO*

### *Seção I*

### *Das normas gerais*

*Art. 5º As alienações serão realizadas por meio de procedimento competitivo para obtenção do melhor retorno econômico para a sociedade de economia mista.*

*§ 1º Quando conflitantes com o procedimento regido por este Decreto, serão respeitados os direitos dos acionistas e as obrigações decorrentes de acordos previamente estabelecidos relativos à participação societária ou ao ativo, bem como a confidencialidade de informações estratégicas protegidas por sigilo legal da sociedade de economia mista, da participação societária ou do ativo ou de informações relacionadas ao próprio procedimento competitivo de alienação.*

*§ 2º Os sócios, os acionistas ou os parceiros poderão afastar normativos internos de procedimento competitivo de alienação para adotar o procedimento de que trata este Decreto, com vistas à padronização da sistemática de alienação de participação societária ou de ativo em comum.*

*Art. 6º O procedimento competitivo de alienação de que trata este Decreto não se aplica às seguintes hipóteses:*

*I - as alienações de ativos que sigam procedimentos disciplinados por órgãos ou entidades reguladoras;*

*II - a formação de consórcios com empresas nacionais ou estrangeiras, na condição ou não de empresa líder, com objetivo de expandir atividades, reunir tecnologias e ampliar investimentos aplicados à indústria;*

*III - a dação em pagamento, a permuta e outras hipóteses de inviabilidade de competição, inclusive aquelas decorrentes de direitos previstos em acordos de acionistas; e*

*IV - os casos em que, de acordo com a legislação, seja justificada a inviabilidade de realização do procedimento competitivo de alienação.*

*Parágrafo único. A incidência das normas específicas a que se refere o inciso I do caput afasta a aplicação do procedimento competitivo de alienação de que trata este Decreto apenas naquilo em que conflitarem.*

*Art. 7º O procedimento competitivo de alienação observará os princípios da publicidade e da transparência, que possibilitarão a fiscalização, a conformidade e o controle dos atos praticados pela sociedade de economia mista.*

*§ 1º Excepcionalmente, o órgão estatutário competente da sociedade de economia mista poderá classificar a operação, as suas etapas ou os documentos*

*como sigilosos, desde que a revelação de informações possa gerar prejuízos financeiros para a sociedade de economia mista ou para o ativo objeto da alienação.*

*§ 2º As avaliações econômico-financeiras serão sigilosas, exceto quando exigida a sua publicidade pela legislação societária em vigor.*

*§ 3º O sigilo não será oponível à fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas da União.*

*Art. 8º Caberá à sociedade de economia mista de capital aberto informar o mercado acerca das etapas do procedimento competitivo de alienação, na forma estabelecida na legislação e nas normas editadas por órgãos ou entidades reguladoras.*

*Art. 9º O objeto da alienação será definido de forma clara no documento de solicitação de propostas preliminares e no documento de solicitação de propostas firmes.*

*Art. 10. Durante o procedimento competitivo de alienação, as eventuais alterações no objeto da alienação demandarão a repetição de todo o procedimento.*

*Parágrafo único. As alterações de condições relevantes da alienação que ocorrerem posteriormente a cada fase demandarão a repetição desta fase.*

*Art. 11. As modificações promovidas no documento de solicitação de propostas preliminares e no documento de solicitação de propostas firmes serão divulgadas nos mesmos meios em que forem veiculados os atos originais e será concedido novo prazo para apresentação das propostas.*

*Art. 12. A sociedade de economia mista anulará seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e poderá revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, hipótese em que não haverá obrigação de indenizar.*

*Art. 13. A qualquer tempo, a sociedade de economia mista poderá determinar a realização de diligências para obtenção de esclarecimentos relacionados ao procedimento competitivo.*

*Art. 14. Os interessados em participar dos procedimentos competitivos de alienação previstos neste Decreto deverão comprovar a sua conformidade com regulações e práticas de prevenção à fraude e à corrupção e a aderência aos critérios objetivos para seleção de interessados previstos no § 1º do art. 18.*

### *Seção II*

### *Do procedimento competitivo de alienação*

*Art. 15. O procedimento de alienação observará as seguintes fases:*

*I - preparação;*

*II - consulta de interesse;*

*III - apresentação de propostas preliminares;*

*IV - apresentação de propostas firmes;*

*V - negociação; e*

*VI - resultado e assinatura dos instrumentos jurídicos negociais.*

*§ 1º O início das fases II a IV do caput será divulgado por meio eletrônico em portal mantido pela sociedade de economia mista na internet.*

*§ 2º A apresentação de propostas preliminares poderá ser dispensada a critério da Comissão de Alienação ou da estrutura equivalente.*

*Art. 16. Para fins de seleção da melhor proposta, será utilizado o critério de julgamento de melhor retorno econômico, que será analisado com base no valor da proposta e em outros fatores, tais como responsabilidades e condições comerciais, contratuais, fiscais, trabalhistas, ambientais, entre outros que possam ser reputados relevantes para análise de melhor proposta, desde que devidamente justificado.*

#### *Subseção I*

#### *Da preparação*

*Art. 17. A fase de preparação interna destina-se ao planejamento do procedimento competitivo de alienação e contemplará:*

*I - justificativa, que conterá motivação para a alienação, proposta de estrutura de negócio, percentual do ativo ou da sociedade a ser alienada e indicativo de valor;*

*II - avaliação de impactos comerciais, fiscais, contábeis, trabalhistas, ambientais, societários e contratuais da alienação;*

*III - avaliação da necessidade de licenças e autorizações governamentais; e*

*IV - verificação da aderência da alienação aos objetivos estratégicos da sociedade de economia mista.*

*§ 1º A Comissão de Avaliação ou a estrutura equivalente será composta por, no mínimo, três membros com competência técnica, e lhe competirá a elaboração da avaliação econômico-financeira do ativo.*

*§ 2º Os membros da Comissão de Avaliação não terão vínculo de subordinação com a Comissão de Alienação.*

*§ 3º O relatório com os elementos indicados nos incisos I a IV do **caput**, descritos de forma detalhada, será submetido à aprovação do órgão societário competente previamente ao início do procedimento competitivo de alienação.*

*Art. 18. A Comissão de Alienação ou a estrutura equivalente será composta por, no mínimo, três membros, e lhe competirá a condução do procedimento competitivo de alienação.*

*§ 1º Os membros da Comissão de Avaliação não poderão compor a Comissão de Alienação.*

*§ 2º A Comissão de Alienação será responsável por:*

*I - elaborar critérios objetivos para seleção de interessados, com base nos princípios da transparência, da impessoalidade e da isonomia; e*

*II - submeter os critérios de que trata o inciso I à aprovação pelo órgão societário competente anteriormente ao início do procedimento competitivo de alienação.*

*§ 3º Poderá ser estabelecido, entre outros, o critério de capacidade econômico-financeira como fator de seleção de interessados, de maneira a considerar o valor do ativo e as informações e os dados estratégicos a ele concernentes.*

*Art. 19. Poderá ser contratada instituição financeira especializada independente para efetuar avaliação econômico-financeira formal e independente do ativo e/ou para assessorar a execução e o acompanhamento da alienação.*

*Art. 20. Após a fase de negociação, será contratada, no mínimo, uma instituição financeira especializada independente para atestar o valor justo da alienação sob o ponto de vista econômico-financeiro.*

*Parágrafo único. Fica dispensada a contratação prevista no **caput** na hipótese de o custo da contratação da instituição financeira ser desproporcional ao valor total da alienação do ativo.*

### *Subseção II*
### *Da consulta de interesse*

*Art. 21. Anteriormente ao envio do documento de solicitação de propostas, a sociedade de economia mista verificará o interesse do mercado na alienação pretendida por meio de instrumento de divulgação da oportunidade, observados os termos estabelecidos no § 1º do art. 7º.*

*Art. 22. O instrumento de divulgação da oportunidade conterá o resumo do objeto da alienação, informará os critérios objetivos para participação no procedimento competitivo de alienação e disponibilizará as informações não sigilosas sobre o ativo, em observância ao princípio da publicidade.*

*Parágrafo único. O instrumento de divulgação da oportunidade conterá as informações necessárias para a manifestação de interesse em participar do procedimento de alienação, tais como o prazo e a forma de realização dos atos, e será publicado preferencialmente por meio eletrônico, em portal mantido na internet,observados os termos estabelecidos no § 1º do art. 7º.*

*Art. 23. Aqueles que manifestarem interesse, por escrito, à sociedade de economia mista deverão comprovar o atendimento aos critérios objetivos estabelecidos no instrumento de divulgação da oportunidade, celebrar acordo de confidencialidade e fornecer outras declarações que atestem seus compromissos com a integridade e a conformidade exigidas pela sociedade de economia mista.*

### *Subseção III*
### *Da apresentação de propostas preliminares*

*Art. 24. Encerrada a fase de consulta de interesse, é facultado à Comissão de Alienação solicitar propostas preliminares aos interessados.*

*Art. 25. O instrumento de solicitação das propostas preliminares informará o momento em que as propostas preliminares serão apresentadas, a data e o horário de abertura dessas propostas e as informações e as instruções consideradas necessárias para a formulação das propostas.*

*Parágrafo único. Os interessados que apresentarem proposta preliminar na fase a que se refere o art. 24 poderão desistir dessas propostas sem incorrer em ônus ou penalidades.*

*Art. 26. Anteriormente ao evento de abertura das propostas preliminares, a Comissão de Alienação obterá a avaliação econômico-financeira preliminar do ativo, a ser elaborada pela Comissão de Avaliação e ou pela instituição financeira de que trata o art. 19, se existente.*

*Art. 27. Competirá à Comissão de Alienação, para garantir a isonomia e a impessoalidade, proceder à abertura simultânea das propostas preliminares apresentadas.*

*Art. 28. Ao final da fase a que se refere o art. 24, a Comissão de Alienação classificará as propostas preliminares recebidas, conforme os critérios por ela estabelecidos previamente.*

*Parágrafo único. A Comissão de Alienação realizará as avaliações necessárias para garantir, quando possível, que possam participar da próxima fase, no mínimo, três interessados.*

*Subseção IV*

*Da apresentação de propostas firmes*

*Art. 29. Competirá à Comissão de Alienação encaminhar documento de solicitação de propostas firmes àqueles que tenham manifestado interesse na fase de consulta de interesse ou àqueles que tenham sido classificados na fase de solicitação de propostas preliminares.*

*Art. 30. O documento de solicitação de propostas firmes conterá, no mínimo:*

*I - descrição do objeto da alienação;*

*II - modo de apresentação, limite e modalidade de prestação de garantias, quando necessário; e*

*III - minutas dos instrumentos jurídicos negociais.*

*Parágrafo único. As propostas poderão conter sugestões de alteração dos termos das minutas dos instrumentos jurídicos negociais, as quais serão avaliadas conforme o interesse da sociedade de economia mista.*

*Art. 31. As propostas oferecidas na fase a que se refere o art. 29 vincularão os proponentes, ressalvadas as alterações decorrentes da fase de negociação.*

*Art. 32. Anteriormente ao evento de abertura das propostas, a Comissão de Alienação obterá a avaliação econômico-financeira final do ativo, a ser elaborada pela Comissão de Avaliação.*

*Art. 33. Competirá à Comissão de Alienação, para garantir a isonomia e a impessoalidade, proceder à abertura simultânea das propostas apresentadas.*

*Art. 34. Ao final da fase a que se refere o art. 29, a Comissão de Alienação classificará as propostas recebidas, conforme os critérios estabelecidos no documento de solicitação de proposta.*

*Subseção V*

*Da negociação*

*Art. 35. Realizada e definida a classificação das propostas, a Comissão de Alienação poderá negociar com o interessado mais bem classificado ou, sucessivamente, com os demais interessados, segundo a ordem de classificação, condições melhores e mais vantajosas para a sociedade de economia mista.*

*Parágrafo único. A negociação poderá contemplar condições econômicas, comerciais, contratuais, além de outras consideradas relevantes à alienação.*

*Subseção VI*

*Do resultado e da assinatura dos contratos*

*Art. 36. Competirá à Comissão de Alienação elaborar o relatório final do procedimento competitivo de alienação.*

*Art. 37. Competirá ao órgão estatutário competente da sociedade de economia mista deliberar sobre a alienação nos termos e nas condições propostas pelo interessado mais bem classificado.*

*Art. 38. Aprovada a alienação pelo órgão estatutário competente, a Comissão de Alienação convocará o interessado mais bem classificado para assinatura dos contratos.*

*Parágrafo único. Na hipótese de desistência do interessado mais bem classificado, serão aplicadas as penalidades previstas no documento de solicitação de propostas.*

*CAPÍTULO III*

*DA FISCALIZAÇÃO*

*Art. 39. Os órgãos de controle externo e interno das três esferas de governo fiscalizarão as alienações promovidas pelas sociedades de economia mista, suas subsidiárias e suas controladas, incluídas aquelas domiciliadas no exterior, quanto à economicidade e à eficácia da aplicação do disposto neste Decreto, sob o ponto de vista contábil, financeiro, operacional e patrimonial.*

*§ 1º Para a realização da atividade fiscalizatória de que trata o **caput**, os órgãos de controle terão acesso aos documentos e às informações necessários à realização dos trabalhos, incluídos aqueles classificados como sigilosos pelas sociedades de economia mista, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.*

*§ 2º O grau de confidencialidade será atribuído pelas sociedades de economia mista no ato de entrega dos documentos e das informações solicitados e o órgão de controle com o qual foi compartilhada a informação sigilosa será corresponsável pela manutenção do seu sigilo.*

*§ 3º O acesso dos órgãos de controle às informações referidas neste Capítulo será restrito e individualizado.*

*§ 4º As informações que sejam revestidas de sigilo bancário, estratégico, comercial ou industrial serão assim identificadas e o servidor responsável pela atividade fiscalizatória responderá administrativa, civil e penalmente pelos danos causados às sociedades de economia mista e a seus acionistas em razão de eventual divulgação indevida.*

*§ 5º Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, a qualquer tempo, documentos de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional das sociedades de economia mista no Brasil e no exterior, e os jurisdicionados ficarão obrigados à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, forem determinadas a elas.*

*Art. 40. Os procedimentos competitivos de alienação já concluídos anteriormente à data de publicação deste Decreto ou cujos contratos definitivos já tenham sido assinados não se submeterão ao disposto neste Decreto, nos termos do art. 6º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.*

*§ 1º Em relação aos procedimentos competitivos de alienação já iniciados na data de publicação deste Decreto, caso exercida a faculdade de adesão prevista no art. 3º, § 1º, ficam preservados os atos anteriormente praticados.*

*§ 2º Na hipótese de adesão facultativa aludida no § 1º, será aplicado o procedimento competitivo de alienação disposto neste Decreto às fases posteriores à sua publicação.*

*Art. 41. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.*

*Brasília, 1º de novembro de 2017; 196º da Independência e 129º da República.*

*MICHEL TEMER*

*Dyogo Henrique de Oliveira*

*Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.11.2017".*

Com efeito, a exordial demonstrará com riqueza de detalhes que a norma aqui impugnada:

a) Afasta o princípio licitatório quando a Constituição Federal afirma sua necessidade;

b) Afasta do Congresso Nacional a prerrogativa de deliberação acerca de venda do patrimônio (bens) da União, quando a Constituição exige a participação do Poder Legislativo;

c) Permite a extinção das sociedades de economia mista sem maiores formalidades, através de venda direta (sem autorização do Congresso Nacional), quando a Constituição Federal prescreve a necessidade de lei específica;

d) Invade a esfera de competência reservada à Lei, de modo que se volta contra a Constituição Federal que não admite a existência de Decreto autônomo em substituição ao regular processo legislativo formal;

e) Afasta a incidência, nos processos de desestatização das empresas estatais, dos princípios da administração pública (normas de direito público), asseverando a prevalência exclusiva, do direito privado;

f) Viola a independência do Poder Legislativo Federal;

g) Convalida, via Decreto Autônomo, atos administrativos inconstitucionais já praticados pela União, em ofensa aos princípios da legalidade e moralidade.

II – Dos dispositivos constitucionais violados.

Objetivamente o inquinado Decreto viola diretamente (e não reflexamente) os seguintes preceitos constitucionais, *verbis*:

a) Incisos II, do art. 5º, art. 59 e 84, IV e VI da CF;

b) Artigos 37, XXI, 173, §1º, III e 175 da CF;

c) Artigos 37, XIX e 61, §1º, II, 'e', da CF;

d) Artigo 48, V, da CF;

e) Artigo 2º da CF;

f) Artigo 37, *caput*, da CF;

g) Princípios da Legalidade e Moralidade – art. 37, *caput*, da CF.

III – Breve síntese dos fatos.

Com efeito, no último dia 1º de novembro de 2017, o Senhor Presidente da República, Michel Temer, e o Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Senhor Dyogo Henrique de Oliveira, editaram o Decreto nº 9.188/2017, objetivando, segundo a ementa, *estabelecer regras de governança, transparência e boas práticas de mercado para a adoção de regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais*.

O principal objetivo do Decreto autônomo é o de permitir a alienação de ativos (totais ou parciais) das sociedades de economia mista com mais agilidade e "menos burocracia" (afastamento das normas de direito público), sem qualquer procedimento licitatório ou participação do Congresso Nacional e, supostamente, com maior transparência e imparcialidade.

A edição do Decreto nº 9188/2017 corresponde a uma verdadeira fraude ao processo legislativo definido na Constituição Federal e a diversos outros dispositivos do texto magno, com consequências deletérias para as empresas de economia mista do País e, consequentemente, para a sociedade brasileira.

O Decreto cria as condições supostamente legais e constitucionais para a venda, sem a observância regular dos procedimentos de licitação, de todos os ativos das empresas.

O Decreto estabelece um regime especial de desinvestimento de ativos, com objetivos delineados de transparência e impessoalidade, segurança jurídica, fiscalização, obtenção de maior retorno econômico à sociedade de economia mista, entre outros.

Entretanto, ao mesmo tempo em que supostamente busca alcançar nos processos de alienação e desinvestimentos a almejada transparência e impessoalidade, o Decreto, de forma contraditória, tem como objetivo principal o de permitir a negociação direta entre o Governo (empresas estatais) e os investidores privados interessados (nacionais ou estrangeiros), sem trilhar, como dito, quaisquer das fases públicas do processo licitatório e, consequentemente, afasta o controle prévio direto (da sociedade brasileira) e indireto (dos órgãos de controle).

Nessa toada, inviável afirmar-se que tais processos de venda do patrimônio das sociedades de economia mista serão pautados pela segurança jurídica, quando o próprio Decreto foi editado em total contrariedade à Constituição Federal.

Ademais, o Decreto afasta do Congresso Nacional qualquer deliberação sobre a venda dos ativos (bens da União) dessas empresas estatais, permitindo inclusive, como se verá, a extinção da sociedade de economia mista sem a edição de lei específica, como exige o texto constitucional.

Ademais, não há como concluir que haverá maior retorno financeiro para as empresas sociedades de economia mista, como divisa o Decreto, se não haverá qualquer tipo de competição entre os interessados na aquisição dos ativos que serão colocados à venda (totais ou parciais), haja vista que o objetivo do Decreto, como afirmando ao norte, é a negociação e a venda direta das empresas estatais.

Como se pode antever, não encontra amparo constitucional qualquer ação na seara da desestatização (venda de ativos das sociedades de economia mista), que exclua, de qualquer modo, a participação do Congresso Nacional ou que, de forma generalizada, afaste os princípios da administração pública, notadamente da licitação, na venda do patrimônio público.

O Decreto ora hostilizado viola também o artigo 37 da Constituição Federal, especialmente quando afasta peremptoriamente, do âmbito de sua incidência, os princípios da publicidade (transparência) e da moralidade administrativa.

Enfim, as diversas inconstitucionalidades presentes na norma impugnada serão descortinadas nos tópicos adiantes.

## IV – Do mérito. Das Violações Constitucionais presentes no Decreto.

### 1 - Violação aos incisos II, do artigo 5º, art. 59 e 84, IV e VI da Constituição Federal.

Com efeito, os artigos 1º, 2º, 3º e 4º do Decreto, violam diretamente os preceitos constitucionais acima destacados. Estes dispositivos constitucionais violados prescrevem o seguinte:

> "Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à

> vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
> II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei";
>
> "Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
> I – emendas à Constituição;
> II – leis complementares;
> III – leis ordinárias;
> IV – leis delegadas;
> V – medidas provisórias;
> VI – decretos legislativos;
> VII – resoluções."
>
> "Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
> ...
> IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;
> VI – dispor, mediante decreto, sobre: "

Com efeito, a Constituição Federal em seu art. 59 estabelece como espécies normativas as emendas à constituição, as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos-legislativos e as resoluções.

Os decretos ditos regulamentares (*no caso específico trata-se de Decreto Autônomo que invade esfera reserva à Lei*) por sua vez, não são reconhecidos como lei. Até porque, conforme se observa da própria nomenclatura, eles têm por objetivo único regulamentar, explicar uma determinada legislação, mas jamais criar novos regramentos e impô-los aos administrados, como ocorre com o Decreto nº 9.188/2017, ora questionado.

Por sua vez, o inciso II, do art. 5º da Constituição Federal prescreve que "*Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei*".

Assim, decreto não pode restringir ou estender direitos para além do que prescreve a norma a ser regulamentada, invadindo a competência reservada à lei, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia legislativa.

É o que ocorre na presente realidade. O Decreto nº 9.188, de 1º de novembro de 2017 invade searas especificamente abrangidas pela lei formal, criando novas hipóteses de dispensa de licitação, afastando do processo de privatização as prerrogativas constitucionais do Congresso

Nacional, entre outras iniquidades, exatamente onde a Constituição Federal não o autoriza.

Ora, é pacífico o ensinamento de que o decreto, tal como previsto no art. 84, inciso IV, da Constituição da República, em qualquer esfera política, constitui ato geral e em regra abstrato, expedido com a estrita finalidade de produzir as disposições operacionais necessárias à fiel execução da lei cuja aplicação demanda atuação da Administração Pública.

O Decreto não cria, não restringe e nem amplia direitos. Apenas explicita as condições para o seu exercício, sob pena de violação ao princípio da legalidade, como ocorre na espécie.

Com efeito, o consagrado princípio da legalidade (art. 5º, inciso II) exprime regra há muito conhecida no Direito inglês da *rule of law, not of men*, que disciplina a impossibilidade de o decreto, enquanto ato normativo infra legal, hierarquicamente inferior ao estatuto normativo de que trata, suplantar os limites já delineados pelo legislador, de modo a se voltar contra competência reservada à lei.

Na verdade, o Decreto deve se restringir a auxiliar o correto atendimento à norma legal, o que não ocorre com a edição do ato normativo autônomo ora impugnado.

Sobre o tema, a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

> (...) Os dispositivos constitucionais caracterizadores do princípio da legalidade no Brasil impõem ao regulamento o caráter que se lhe assinalou, qual seja, o de ato normativo subordinado, isto é, meramente subalterno e, ademais, dependente de lei.
>
> (...)
>
> Em consequência, pode-se, com Pontes de Miranda, afirmar: 'Onde se estabelecem, alteram ou extinguem direitos, não há regulamentos - há abuso do poder regulamentar, invasão de competência legislativa. O regulamento não é mais do que auxiliar das leis, auxiliar que sói pretender, não raro, o lugar delas, mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar-se e lograr que o elevem à categoria de lei'. (in Curso de Direito Administrativo, 26ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 341, ss) (g.n).

Nesse sentido, sendo o decreto um ato subordinado, mas que adquire, no caso concreto, pela sua abrangência e temas tratados, natureza eminentemente autônoma, é plenamente reconhecido ao

Judiciário o correspondente controle de constitucionalidade concentrado, na medida em que se imputa violações direta ao texto da Constituição Federal.

Nesta toada, não se pode admitir que o decreto, a pretexto de esclarecer o fiel cumprimento da lei de que trata, usurpe suas competências, inove a ordem jurídica, cuidando de matéria que suplanta o limite já evidenciado pela norma legislativa.

Do cotejo das normas, fica evidente que o Decreto supra, conquanto tivesse a pretensão inicial de dar vazão ao poder regulamentar, já foi editado com características eminentemente autônomas, porquanto instituiu novo regramento ao regime de desinvestimento das sociedades de economia mista não previsto na própria norma de regência, de modo que se volta diretamente contra a própria Constituição Federal, ao excepcionar, por exemplo, o procedimento licitatório em situações em que tanto a Lei, como a Constituição Federal expressamente exigem esse processo de competição pública.

Vale reprisar que de acordo com o princípio constitucional da hierarquia das normas, "o decreto está sempre em situação inferior à da lei e, por isso mesmo, não a pode contrariar" (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito. Administrativo. 26 Ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 171).

Nesse sentido:

> "O decreto, como norma secundária - que tem função eminentemente regulamentar, conforme o art. 84, inc. IV, da Constituição Federal -, não pode contrariar ou extrapolar a lei, norma primária. Não pode restringir os direitos nela preconizados. Isso porque tão-somente a lei, em caráter inicial, tem o poder de inovar no ordenamento jurídico (RMS n. 22.828/SC, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.3.2008).

Celso Antônio Bandeira de Mello, ao discorrer sobre o assunto, ensina o seguinte:

> O Texto Constitucional brasileiro, em seu art. 5º, II, expressamente estatui que: "Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Note-se que o preceptivo não diz "decreto", "regulamento", "portaria", "resolução" ou quejandos. Exige lei para que o Poder Público possa impor obrigações aos administrados. É que a Constituição brasileira, seguindo tradição já antiga, firmada por suas antecedentes republicanas, não quis tolerar que o Executivo, valendo-se de regulamento, pudesse, por si mesmo, interferir com a liberdade ou a propriedade das pessoas.

[...]

Consagra-se, em nosso Direito Constitucional, a aplicação, plena, cabal, do chamado princípio da legalidade, tomado em sua verdadeira e completa extensão. Em conseqüência, pode-se, com Pontes de Miranda, afirmar: "Onde se estabelecem, alteram ou extinguem direitos, não há regulamentos - há abuso de poder regulamentar, invasão de competência legislativa. O regulamento não é mais do que auxiliar das leis, auxiliar que sói pretender, não raro, o lugar delas, mas sem que possa, com tal desenvoltura, justificar-se e lograr que o elevem à categoria de lei".

[...]

De outro lado, conjugando-se o disposto no artigo citado com o estabelecido no art. 84, IV, que só prevê regulamentos para "fiel execução das leis", e com o próprio art. 37, que submete a Administração ao princípio da legalidade, resulta que vige, na esfera do Direito Público, um cânone basilar - oposto ao da autonomia da vontade -, segundo o qual: o que, por lei, não está antecipadamente permitido à Administração está, ipso facto, proibido, de tal sorte que a Administração, para agir, depende integralmente de uma anterior previsão legal que lhe faculte ou imponha o dever de atuar.

Por isto deixou-se dito que o regulamento, além de inferior, subordinado, é ato dependente de lei (in Curso de Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006, p. 326-329).

No mesmo sentido, leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

"Ao editar as leis, o Poder Legislativo nem sempre possibilita que sejam elas executadas. Cumpre, então, à Administração criar os mecanismos de complementação das leis indispensáveis a sua efetiva aplicabilidade. Essa é a base do poder regulamentar.

Poder regulamentar, portanto, é a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. A prerrogativa, registre-se, é apenas para complementar a lei; não pode, pois, a Administração alterá-la a pretexto de estar regulamentando. Se o fizer, cometerá abuso de poder regulamentar, invadindo a competência do Legislativo. (...)

O poder regulamentar é subjacente à lei e pressupõe a existência desta. É com esse enfoque que a Constituição autorizou o Chefe do Executivo a expedir decretos e regulamentos: viabilizar a efetiva execução das leis (art. 84, IV).

> Por essa razão, ao poder regulamentar não cabe contrariar a lei (contra legem), pena de sofrer invalidação. Seu exercício somente pode dar-se secundum legem, ou seja, em conformidade com o conteúdo da lei e nos limites que esta impuser. Decorre daí que não podem os atos formalizadores criar direitos e obrigações, porque tal é vedado num dos postulados fundamentais que norteiam nosso sistema jurídico: 'ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei' (art. 5º, II, CF)" (Manual de Direito Administrativo. 30ª edição. São Paulo, Atlas, 2014, p. 59 e 61).

Nessa perspectiva, o Decreto nº 9.188, de 1º de novembro de 2017, notadamente seus artigos 1º e 2º, violam flagrantemente os dispositivos constitucionais insculpidos no inciso II, do art. 5º (Princípio da Legalidade), art. 59 e 84, IV e VI da Constituição Federal.

2 – Violação aos arts. 37, XXI, 173, §1º, III e 175 da Constituição Federal.

Os artigos 1º a 38 do Decreto inquinado, quando criam o *Regime Especial de Desinvestimento das Sociedades de Economia Mista* e um novo *Procedimento Competitivo de Alienação*, fulcrado eminentemente na dispensa de licitação e na venda direta de ativos totais ou parciais das sociedades de economia mista, se chocam diretamente com os dispositivos constitucionais acima destacados, que prescrevem o seguinte:

> "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
>
> ...
>
> XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. "

> "Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

> §1º - A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:
>
> III – licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; ”
>
> “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. ” (g.n).

Ora, é entendimento pacificado na Constituição Federal, que a venda de ativos (patrimônio das empresas estatais), não pode prescindir de prévio processo licitatório, como estatui o artigo 37 e seu inciso XXI, do texto maior da República.

Já o inciso III, §1º do art. 173 é enfático quando prescreve a necessidade de licitação na seara das atividades das sociedades de economia mista, ressalvando inclusive, a incidência das normas de direito público.

Por sua vez, o art. 175 da Constituição Federal prevê que os serviços públicos podem ser prestados diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, na forma da lei, mas sempre através de licitação.

Segundo o ex-ministro Octávio Gallotti (RExtr. nº 140.989), *“este advérbio (“sempre”), enfaticamente utilizado no art. 175 da Lei Fundamental, não dá margem alguma de dúvida sobre a eficácia plena, imediata e automática do preceito, que está a obrigar, tanto o legislador e o poder regulamentar, quanto a vincular o ato concreto de concessão à prévia licitação toda vez que não se trate de exploração direta do serviço pelo Poder Público”.*

O ordenamento jurídico não abre espaço para disposição do patrimônio público sem o prévio procedimento licitatório. Assim, a pretensão de convalidação de tais atos sem observância das formalidades exigidas pela Administração Pública, como faz o Decreto nº 9.188, de 2017, fere princípios regentes do Estado brasileiro que coloca a Licitação como um dos principais pilares da Administração Pública.

O compromisso maior com os princípios da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência vem ao encontro da finalidade constitucional conferida ao regime da licitação pública, que visa propiciar igualdade de condições e oportunidades para todos, além de atuar como fator de transparência e moralidade dos negócios públicos, não podendo jamais tais princípios serem suplantados por um Decreto autônomo, que se pretende com força maior que a própria Constituição da República.

Desse modo, é inviável admitir a possibilidade de transferência no processo de venda de ativos das sociedades de economia mista sem assegurar o devido processo licitatório constitucional.

Por meio do processo licitatório, conforme ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, atende-se a três exigências públicas impostergáveis: proteção aos interesses públicos e recursos governamentais, respeito aos princípios da isonomia e impessoalidade e, finalmente, obediência aos reclamos da probidade administrativa, tão caros ao Estado Democrático de Direito da contemporaneidade. (Curso de Direito Administrativo. 26.ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 519)

A licitação, isto é, o procedimento administrativo destinado a selecionar a proposta mais vantajosa, é obrigatório para as contratações da Administração Pública em geral que tenham por objeto obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações.

Essa obrigatoriedade vem expressa na Constituição da República, nos seguintes termos: *'Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações' (art. 37, XXI)*." (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato. Administrativo. 13. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2002).

Nos dispositivos destacados acima, são reafirmados expressamente, o postulado ético-jurídico constante da Constituição Federal (art. 5°, caput, art. 37, caput e XXI, CF e art. 175, CF), e defluente dos princípios gerais do Direito, segundo o qual a prévia contratação (gênero) com o Poder Público, gerando, potencialmente, benefícios

econômico-financeiros exclusivos a certos particulares, pressupõe obediência à prática moralizante, republicana e isonômica da prévia licitação, assegurando a todos os interessados igualdade na disputa pelas vantagens resultantes da (a) prestação indireta de serviços públicos, da (b) realização de obras públicas, dos (c) contratos em que proponente a Administração, ou (d) do uso em prol individual de bens do domínio público - mesmo que, neste caso, não exista exigência constitucional expressa.

Nesse sentido é a clássica lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, ao discorrer sobre a obrigatoriedade de prévia licitação para os atos administrativos ampliativos de direitos ou prerrogativas de terceiros (particulares):

> "É a própria Constituição que a impõe, no art. 37, XXI, cujos termos são os seguintes: 'ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações'.
>
> 'Tal dispositivo contém comandos que, como ao diante se verá, introduzem importantes balizamentos a quaisquer normas infraconstitucionais que regulem a licitação e contratos administrativos no país.
>
> 'Esta mesma exigência é reiterada especificamente para as concessões e permissões de serviçi público no art. 175, o qual se vale, inclusive, de enérgica linguagem, ao estabelecer que serão 'sempre' precedidas de licitação. É bem de ver que outro tanto se passará no caso das concessões de obras públicas, até mesmo porque no Direito brasileiro, tal como as de serviço, são consideradas 'contratos'. Por isto, umas e outras já se encontram genericamente abrangidos pelo precitado art. 37.
>
> 'Aliás, deve-se entender que o simples princípio da igualdade de todos perante a lei (art. 5° da CF) e, a fortiori, perante a Administração - obrigada a agir com 'impessoalidade', nos termos do art. 37, caput, da Lei Magna -, normalmente imporá licitação também no caso de permissões de uso exclusivo de bem público ou de qualquer outro ato ampliativo que se destine a investir terceiros no desfrute de situação jurídica especial a que mais de um poderia aspirar (...).
>
> 'Pode-se conceituar a licitação da seguinte maneira: é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, outorgar concessões, permissões de

> obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca os interessados na apresentação das propostas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em função dos parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados. ' (Curso de Direito Administrativo. 16ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 480/481).

Com efeito. A reunião lógica dos princípios que integram o regime constitucional, exigindo, como expressão da impessoalidade, a prévia licitação para as contratações com o Poder Público, levam mesmo à conclusão de que tal exigência se estende, embora omisso texto (literal) da Constituição, também às concessões e permissões de exploração de bens públicos e à alienação de ativos dessas empresas estatais, exigência que passa a ostentar, implicitamente, *status* constitucional para efeito de funcionar como norma-parâmetro de controle, em atenção à própria noção de blocos de constitucionalidade, avançada na doutrina do ramo (cf. Pedro Lenza. Direito Constitucional Esquematizado. 10ª ed. São Paulo: Método, 2006, p. 129) e ampliativa dos paradigmas de confronto para neles incluir não só as normas formalmente constitucionais, mas também os princípios não-inscritos da ordem constitucional global e valores suprapositivos.

Na observação do Ministro Celso de Mello:

> 'Vale referir, neste ponto, que a discussão das questões suscitadas nesta sede de fiscalização normativa abstrata permite, a esta Suprema Corte, elaborar - como é típico dos Tribunais Constitucionais - a construção de um significado mais amplo em torno do conceito de Constituição, considerando, para esse efeito, não apenas os preceitos de índole positiva, expressamente proclamados no documento formal que consubstancia o texto escrito da Carta Política, mas reconhecendo, por igualmente relevantes, em face da sua transcendência mesma, os valores de caráter suprapositivo e o próprio espírito que informam e dão sentido e razão à Lei Fundamental do Estado.
>
> 'Não foi por outra razão que o Supremo Tribunal Federal, certa vez, e para além de uma perspectiva meramente reducionista, veio a proclamar, distanciando-se, então, das exigências inerentes ao positivismo jurídico, que a Constituição da República, muito mais do que o conjunto de normas e princípios nela formalmente positivados, há de ser entendida em função do próprio espírito que a anima, afastando-se, desse modo, de uma concepção impregnada de evidente minimalismo conceitual (RTJ 71/289, 292 - RTJ 77/657). (...)

'A busca do paradigma de confronto, portanto, significa, em última análise, a procura de um padrão de cotejo, que, ainda em regime de vigência temporal, permita, ao intérprete, o exame da fidelidade hierárquico-normativa de determinado ato estatal contestado em face da Constituição. (...)

'Sob tal perspectiva, que acolhe conceitos múltiplos de Constituição, pluraliza-se a noção mesma de constitucionalidade-inconstitucionalidade, em decorrência de formulações teóricas, matizadas por visões jurídicas e ideológicas distintas, que culminam por determinar - quer elastecendo-as, quer restringindo-as - as próprias referências paradigmáticas conformadoras do significado e do conteúdo material inerentes à Carta Política.

'Torna-se relevante destacar, neste ponto, por tal razão, o magistério de J.J. Gomes Canotilho (''Direito Constitucional e Teoria da Constituição', p. 811/812, item n. 1, 1988, Almedina), que bem expôs a necessidade de proceder-se à determinação do parâmetro de controle de constitucionalidade, consideradas as posições doutrinárias que se digladiam em torno do tema:

'Todos os actos normativos devem estar em conformidade com a Constituição (art. 3°/3). Significa isto que os actos legislativos e restantes actos normativos devem estar subordinados, formal, procedimental e substancialmente ao parâmetro constitucional. Mas qual é o estalão normativo de acordo com o qual se deve controlar a conformidade dos actos normativos. As respostas a este problema oscilam de acordo fundamentalmente entre duas posições: (1) o parâmetro constitucional equivale à constituição escrita ou leis com valor constitucional formal, e daí que a conformidade dos actos normativos só possa ser aferida, sob o ponto de vista da sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade, segundo as normas e princípios escritos na Constituição (ou outras leis formalmente constitucionais); (2) o parâmetro constitucional é a ordem constitucional global, e, por isso mesmo, o juízo de legitimidade constitucional dos actos normativos deve fazer-se não apenas segundo as normas e princípios escritos das leis constitucionais, mas também tendo em conta princípios não escritos integrantes da ordem constitucional global.

'Na perspectiva (1), o parâmetro da constitucionalidade (= normas de referência, bloco de constitucionalidade) reduz-se às normas e princípios da constituição e das leis com valor constitucional; para a posição (2), o parâmetro constitucional é mais vasto do que as normas e princípios constantes das leis constitucionais escritas, devendo alargar-se, pelo menos, aos princípios reclamados pelo 'espírito' ou pelos 'valores' que informam a ordem constitucional global'.

> 'Vê-se, pois, a importância de compreender-se, com exatidão, o significado que emerge da noção de bloco de constitucionalidade - tal como é concebido pela teoria constitucional (...) (STF. ADC-MC n. 12, Rel. Min. Carlos Britto, no voto do Min. Celso de Mello).

Verifica-se, portanto, que o novo *Regime Especial de Desinvestimento das Sociedades de Economia Mista*, que será viabilizado, o que se admite apenas para argumentar, através do novo *Procedimento Competitivo de Alienação*, ao promover a venda de ativos das empresas estatais sem qualquer procedimento licitatório, viola o texto constitucional que exige, nessa realidade, a realização de prévia licitação para alienação dos bens públicos.

## 3 – Violação aos Artigos 37, XIX e 61, §1º, II, 'e', da Constituição Federal.

Com efeito, os parágrafos 3º e 4º, II, do artigo 1º do Decreto estatuem o seguinte:

> "Art. 1º (...)
> §3º O regime de que trata o caput poderá abranger a alienação parcial ou total de ativos.
> §4º Para os fins do disposto neste Decreto, consideram-se:
> ...
> II – alienação – qualquer forma de transferência total ou parcial de ativos para terceiros. (g.n).

Vejam Excelências, que o dispositivo permite a venda total dos ativos da empresa, o que na prática, configura a própria extinção ou "canibalização" da sociedade, que resultará no fim da estatal ou, sem suas características e patrimônios originais, numa existência apenas simbólica, inclusive com a possibilidade de assunção de dívidas exclusivamente pelo Estado brasileiro.

Nesse diapasão, tem-se que os trechos destacados do Decreto violam os seguintes dispositivos constitucionais:

> "Art. 37 (...)
> XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir suas áreas de atuação. "

> "Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
>
> §1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
>
> II – disponham sobre:
>
> e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;"

Ora, se para a criação de sociedade de economia mista há necessidade de lei específica, com muito mais razão e até mesmo em função do princípio do paralelismo, também para a extinção da sociedade de economia mista (processo que ocorre com a venda total de ativos) haverá necessidade de lei específica, não a suprindo, por óbvio, um Decreto autônimo.

Nesse sentido, o excerto do texto "PARECER SOBRE A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 9.188, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2017, da lavra do Professor GILBERTO BERCOVICI (doc. 2):

> "(...)
>
> Da mesma forma que a sociedade de economia mista deve ter sua criação autorizada por lei (artigo 37, XIX da Constituição), ela só pode ser extinta por lei ou na forma da lei. Esta necessidade de autorização legislativa para a extinção das empresas estatais em geral (inclusive as sociedades de economia mista) sempre foi defendida pela doutrina administrativa brasileira, estando hoje consagrada no artigo 61, §1º, II, e, da Constituição de 1988, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001.
>
> Não pode, portanto, um mero decreto determinar uma política de alienação de ativos das sociedades de economia mista que pode comprometer a sua própria existência e continuidade, uma espécie de privatização disfarçada, como faz o Decreto nº 9.188/2017. O Decreto nº 9.188/2017, inclusive, cria uma nova forma de desestatização, o desinvestimento (alienação de ativos) sem licitação prévia (...).
>
> Sob a Constituição de 1988, as empresas estatais estão subordinadas às finalidades do Estado, como o desenvolvimento (artigo 3º, II da Constituição). Nesse sentido, é correta a afirmação de Paulo Otero, para quem o interesse público é o fundamento, o limite e o critério da iniciativa econômica pública. A legitimação constitucional, no caso brasileiro, desta iniciativa econômica pública, da qual as

> sociedades de economia mista constituem exemplos, se dá pelo cumprimento dos requisitos constitucionais e legais fixados para a sua atuação. Os objetivos das empresas estatais estão fixados por lei, não podendo furtar-se a estes objetivos. Devem cumpri-los, sob pena de desvio de finalidade. Para isso foram criadas e são mantidas pelo Poder Público. (...)

Esclarecedor, da mesma forma, o parecer da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (disponível em file:///C:/Users/P_112330/Downloads/206-773-2-PB%20(1).pdf – pesquisado em 23.11.17), quando assevera (doc. 3):

> "(...)
> Quanto à necessidade de legislação específica autorizando a incorporação (ou outra forma de extinção) das pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, no passado já se tentou conferir ao Chefe do Poder Executivo uma autorização genérica para fazê-lo. Entretanto, com a evolução legislativa e doutrinária sobre a questão, dúvidas não há quanto à exigência de autorização específica, conforme ensinamentos de Maria Sylvia Zanella di Pietro:
>
> > 'Quanto à extinção das empresas públicas e sociedades de economia mista (bem como das autarquias e fundações), o artigo 178 do Decreto-lei n.º 200/67 previa a possibilidade da sua liquidação ou incorporação a outras entidades, "por ato do Poder Executivo, respeitados os direitos assegurados aos eventuais acionistas minoritários, se houver, nas leis e atos constitutivos de cada entidade". Esse dispositivo sempre foi criticado pelos doutrinadores, por atribuir ao Poder Executivo a possibilidade de desfazer ato do legislador, sendo, portanto, inconstitucional. Na atual Constituição, ficou fora de dúvida sua revogação, pois a competência do Presidente da República para dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Federal, que era invocada para justificar aquela norma, passou a ser exercida "na forma da lei" (art. 84, VI, em sua redação original). Esse dispositivo foi alterado pela Emenda Constitucional n.º 32/2000, que deu competência ao Presidente da República para dispor, por decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, porém quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. A mesma Emenda Constitucional também alterou o artigo 61, § 1º, alínea e, exigindo lei de iniciativa do Presidente

> da República para a criação e extinção de Ministérios e órgão da administração pública. Se a exigência é feita para órgãos (que não têm personalidade jurídica própria), com muito mais razão se justifica em relação aos entes da administração indireta, que são pessoas jurídicas distintas da pessoa política que as instituiu'.

No mesmo sentido, José dos Santos Carvalho Filho é categórico em afirmar que para implementar a extinção da empresa pública ou sociedade de economia mista é necessária lei autorizadora prévia:

> 'A extinção das empresas públicas e das sociedades de economia mista reclama lei autorizadora. Significa dizer que o Poder Executivo, a que são normalmente vinculadas, não tem competência exclusiva para dar fim às entidades. O fato se justifica pela teoria da simetria, isto é, se a própria Constituição exige que a autorização criadora se faça através de lei, é evidente que somente ato desta natureza será legítimo para extingui-las'.

Portanto, desde que haja prévia autorização legislativa, dúvidas não há quanto à possibilidade de uma empresa estatal ser incorporada e de ser, conseqüentemente, extinta. Vale ressaltar que essa autorização legislativa precisa ser específica, isto é, deve indicar que a extinção deverá ser feita por incorporação, e não por outra forma. Sendo assim, uma eventual lei que autorize a liquidação de determinada empresa estatal não pode ser utilizada por analogia, quando se pretender a extinção por incorporação dessa empresa estatal.

Para a extinção de empresa estatal por incorporação é necessária prévia autorização legal, mas não é exigida tal autorização legal quando a empresa estatal é que pretender incorporar o patrimônio de outra pessoa jurídica empresarial. Quando a empresa estatal assume o papel de incorporadora, não se faz necessária a prévia autorização legislativa, mas se ambas, incorporadora e incorporada, forem empresas estatais, é conveniente que a lei que autorizará a incorporação, além de mencionar a empresa estatal incorporada, também identifique a empresa estatal incorporadora – procedimento este que é relevante para conferir mais publicidade à operação. (...)"

Ao permitir a venda total dos ativos das sociedades de economia mista, impondo como consequência a extinção formal ou material da Companhia, os dispositivos destacados do Decreto autônomo

violam frontalmente os artigos 37, XIX e 61, §1º, II, 'e' da Constituição Federal.

4 – Violação ao Art. 48, V, da Constituição Federal.

O Decreto autônomo editado, como se vem afirmando, afasta peremptoriamente a participação do Congresso Nacional de quaisquer deliberações acerca da venda de ativos das empresas estatais.

Ocorre que os artigos 44 a 52 da Constituição, com as ressalvas expressamente destacadas no art. 48, V prescrevem que o Congresso Nacional, por suas casas, participam obrigatoriamente de toda a formulação da política federal de investimentos e das medidas administrativas e políticas (licitações, desinvestimentos, privatizações, contratações etc) propostas pelo Executivo, de modo que não há espaço, na quadra constitucional vigente, para tratamento dessas matérias, como faz o Chefe do Poder Executivo, exclusivamente por meio de Decreto autônomo editado pelo Presidente da República.

Na verdade, a Constituição Federal é bastante clara quando afirma que os processos de alienação de bens públicos (venda de ativos das estatais por exemplo) devem ser precedidos de autorização legislativa e, consequentemente, da ampla participação do Congresso Nacional.

E no caso específico do presente Decreto autônomo a autorização do Congresso Nacional se mostra ainda mais necessária, na medida em que a norma impugnada permite, como demonstrado acima, a alienação total dos ativos das empresas estatais, o que configura, como dito, a transferência ou, mais diretamente, a perda do controle acionário da União (sociedade brasileira) acerca desse patrimônio.

Assim, o Decreto autônomo ora questionado, em sua totalidade, viola o seguinte dispositivo constitucional:

> "Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos art. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
>
> V – limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União; "

Esse Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de se manifestar acerca dessa exigência, nos seguintes termos:

“ADI 234 / RJ - RIO DE JANEIRO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA
Julgamento: 22/06/1995 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação - DJ 15-09-1995 PP-29628 - EMENT VOL-01800-01 PP-00023.
Parte(s)
REQTE.: GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADV.: JOSE EDUARDO SANTOS NEVES E OUTROS
REQDO.: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Ementa
Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 69 e parágrafo único, e art. 99, inciso XXXIII. Alienação, pelo Estado, de ações de sociedade de economia mista. 2. Segundo os dispositivos impugnados, as ações de sociedades de economia mista do Estado do Rio de Janeiro não poderão ser alienadas a qualquer título, sem autorização legislativa. Mesmo com autorização legislativa, as ações com direito a voto das sociedades aludidas só poderão ser alienadas, sem prejuízo de manter o Estado, o controle acionário de 51% (cinquenta e um por cento), competindo, em qualquer hipótese, privativamente, a Assembleia Legislativa, sem participação, portanto, do Governador, autorizar a criação, fusão ou extinção de empresas públicas ou de economia mista bem como o controle acionário de empresas particulares pelo Estado. 3. O art. 69, "caput", da Constituição fluminense, ao exigir autorização legislativa para a alienação de ações das sociedades de economia mista, é constitucional, desde que se lhe confira interpretação conforme a qual não poderão ser alienadas, sem autorização legislativa, as ações de sociedades de economia mista que importem, para o Estado, a perda do controle do poder acionário. Isso significa que a autorização, por via de lei, há de ocorrer quando a alienação das ações implique transferência pelo Estado de direitos que lhe assegurem preponderância nas deliberações sociais. A referida alienação de ações deve ser, no caso, compreendida na perspectiva do controle acionário da sociedade de economia mista, pois é tal posição que garante a pessoa administrativa a preponderância nas de liberações sociais e marca a natureza da entidade. 4. Alienação de ações em sociedade de economia mista e o "processo de privatização de bens públicos". Lei federal n. 8031, de 12.4.1990, que criou o Programa Nacional de Desestatização. Observa-se, pela norma do art. 2., parágrafo 1., da lei n. 8031/1990, a correlação entre as noções de "privatização" e de "alienação pelo Poder Público de direitos concernentes ao controle acionário das sociedades de economia mista", que lhe assegurem preponderância nas

deliberações sociais. 5. Quando se pretende sujeitar a autorização legislativa a alienação de ações em sociedade de economia mista. Importa ter presente que isto só se faz indispensável, se efetivamente, da operação, resultar para o Estado a perda do controle acionário da entidade. Nesses limites, de tal modo, é que cumpre ter a validade da exigência de autorização legislativa prevista no art. 69 "caput", da Constituição fluminense. 6. Julga-se, destarte, em parte, procedente, no ponto, a ação, para que se tenha como constitucional, apenas, essa interpretação do art. 69, "caput", não sendo de exigir-se autorização legislativa se a alienação de ações não importar perda do controle acionário da sociedade de economia mista, pelo Estado. 7. É inconstitucional o parágrafo único do art. 69 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro ao estipular que " as ações com direito a voto das sociedades de economia mista só poderão ser alienadas, desde que mantido o controle acionário, representado por 51% (cinquenta e um por cento) das ações". Constituição Federal, arts. 170,173 e parágrafos, e 174. Não é possível deixar de interpretar o sistema da Constituição Federal sobre a matéria em exame em conformidade com a natureza das atividades econômicas e, assim, com o dinamismo que lhes é inerente e a possibilidade de aconselhar periódicas mudanças nas formas de sua execução, notadamente quando revelam intervenção do Estado. O juízo de conveniência, quanto a permanecer o Estado na exploração de certa atividade econômica, com a utilização da forma da empresa pública ou da sociedade de economia mista, há de concretizar-se em cada tempo e avista do relevante interesse coletivo ou de imperativos da segurança nacional. Não será. Destarte, admissível, no sistema da Constituição Federal que norma de Constituição estadual proíba, no Estado-membro, possa este reordenar, no âmbito da própria competência, sua posição na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidas ou, desnecessariamente exploradas pelo setor público. 8. Não pode o constituinte estadual privar os Poderes Executivo e Legislativo do normal desempenho de suas atribuições institucionais, na linha do que estabelece a Constituição Federal, aplicável ao Estados-membros. 9. É também, inconstitucional o inciso XXXIII do art. 99 da Constituição fluminense, ao atribuir competência privativa a Assembleia Legislativa." Para autorizar a criação, fusão ou extinção de empresas públicas ou de economia mista bem como o controle acionário de empresas particulares pelo Estado". Não cabe excluir o Governador do Estado do processo para a autorização legislativa destinada a alienar ações do Estado em sociedade de economia mista. Constituição Federal, arts. 37, XIX, 48, V, e 84, VI, combinados com os arts. 25 e 66. 10. Ação direta.de inconstitucionalidade julgada procedente, em parte, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art.

> 69 do inciso XXXIII.do art. 99, ambos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, bem assim para declarar parcialmente inconstitucional o art. 69, "caput", da mesma Constituição, quanto a todas as interpretações que não sejam a de considerar exigível a autorização legislativa somente quando a alienação de ações do Estado em sociedade de economia mista implique a perda de seu controle acionário." (g.n).

Desse modo, ao pretender realizar inclusive a venda total dos ativos das sociedades de economia mista sem qualquer participação do Congresso Nacional, o Decreto autônomo viola flagrantemente o art. 48, V da Constituição Federal.

## 5 – Violação ao Art. 2º da Constituição Federal.

Como dito no princípio da vertente inicial, ao criar o *Regime Especial de Desinvestimento das Sociedades de Economia Mista* e, consequentemente, *o Procedimento Competitivo de Alienação de Ativos*, o Decreto autônomo inquinado também afasta a participação do Congresso Nacional na política de privatização das empresas estatais, em clara violação ao princípio constitucional da Independência dos Poderes, na medida em que esvazia ou tenta esvaziar, o papel constitucional e as altas responsabilidades do Poder Legislativo na implantação desta política de desinvestimentos.

O artigo 2º da Constituição Federal, ora violado pelo Decreto, prescreve:

> "Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário".

O Decreto tem o condão de regular, sem a participação do Congresso Nacional, por exemplo, novas formas de dispensa de licitação não avalizada no texto constitucional o que demonstra sua incompatibilidade (invasão de competência) com o princípio da independência e harmonia entre os Poderes.

Como visto acima, o Decreto também permite a extinção das empresas estatais sem qualquer participação do Congresso Nacional, além de possibilitar, entre outras inconstitucionalidades, a convalidação de atos ilegais, tudo sem que o Poder Legislativo possa se pronunciar.

O Decreto autônomo subordina diversas prerrogativas e competências do Poder Legislativo à vontade do Poder Executivo de

executar a toque de caixa, a qualquer custo, o processo de venda dos ativos das empresas estatais.

Sobre a independência e harmonia dos Poderes, já ensinava João Barbalho, em seus Comentários à Constituição Federal de 1891 que "a Constituição os estatui harmônicos, devendo cada qual respeitar a esfera de atribuições dos outros e exercer as próprias de modo que nunca de embaraço, mas de facilidade e coadjuvação, sirvam às dos demais, colaborando todos assim, a bem da comunhão" (vol. 3, RJ., 1902, pág. 163).

A lição é antiga, mas de difícil assimilação por aqueles a quem se destina. O mau hábito da sobreposição de interesses que são outros aos interesses da coletividade fica evidente no contexto ora apreciado, pela notoriedade das razões que justificaram a edição do Decreto impugnado.

Leciona ALEXANDRE DE MORAES, agora Ministro do Supremo Tribunal Federal que:

> "Ao prelecionar sobre a divisão dos poderes, Montesquieu mostrava o necessário para o equilíbrio dos poderes, afirmando que, para formar-se um governo moderado 'precisa-se combinar os poderes, regrá-los, temperá-los, fazê-los agir; dar a um poder, por assim dizer, um lastro, para pô-lo em condições de resistir a um outro. É uma obra-prima de legislação, que raramente o acaso produz, e raramente se deixa a prudência produzir (...). Sendo o seu corpo legislativo composto de duas partes, uma acorrentada a outra pela mútua faculdade de impedir. Ambas serão amarradas pelo Poder Executivo, o qual o será, por seu turno, pelo Legislativo. Esses três poderes deveriam originar um impasse, uma inação. Mas como, pelo movimento necessário das coisas, são compelidos a caminhar, eles haverão de caminhar em concerto'. (...) Ocorre, porém, que, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional..." (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 6ª ed., São Paulo: Altas, 2006, p. 137).

É cediço que a separação dos poderes constitui premissa básica de todo ente federado, dada a insigne previsão constitucional. Tal princípio possui expressão no artigo 2º da Constituição Federal. Tais dispositivos dispõem que 'são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário'.

O poder estatal, que na verdade é uno, caracteriza-se então pelo exercício distinto das funções legislativa, executiva e judiciária. Concomitantemente a essa separação de poderes, tem-se a doutrina do sistema de freios e contrapesos (checks and balances) que justifica os postulados de independência e harmonia, garantindo a interação e o controle recíproco entre os poderes.

Esse controle recíproco, proveniente do Sistema de Freios e Contrapesos, permite a interferência de um Poder em relação ao outro em casos específicos, cabendo inclusive às Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais observar os moldes estabelecidos pela Constituição Federal.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que 'do relevo primacial dos 'pesos e contrapesos' no paradigma de divisão dos poderes, segue-se que à norma infraconstitucional - aí incluída, em relação à Federal, a constituição dos Estados-membros -, não é dado criar novas interferências de um Poder na órbita de outro que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental da República.' (STF. ADI 3046. Rel.: Min. Sepúlveda Pertence, 15.04.2004).

Para a efetividade do princípio da separação dos Poderes do Estado é necessário que ente obedeça às regras de competência relativas à iniciativa privativa de lei, previamente definidas na Constituição, sob pena de se comprometer a própria existência do Poder. A propósito, extrai-se da lição de José Afonso da Silva:

> "A divisão de poderes fundamenta-se, pois, em dois elementos: a) especialização funcional, significando que cada órgão é especializado no exercício de uma função; assim às Assembleias (Congresso, Câmaras, Parlamento) se atribui a função legislativa, ao Executivo, a função executiva, ao Judiciário, a função jurisdicional; b) independência orgânica significando que além da especialização funcional é necessário que cada órgão seja efetivamente independente dos outros, o que postula ausência de meios de subordinação. [...] Por sua vez a independência dos poderes significa: a) que a investidura e a permanência das pessoas num dos órgãos do governo não dependem da confiança nem da vontade dos outros; b) que no exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os titulares consultar os outros nem necessitam de sua autorização; c) que, na organização dos respectivos serviços, cada um é livre, observadas apenas as disposições

> constitucionais e legais [...]" (Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo, Malheiros, 1992, págs. 99/100).

Assim, também por vulnerar o princípio da independência e harmonia entre os Poderes, o questionado Decreto deve ser afastado do mundo jurídico. É o que se requer.

## 6 – Violação ao Art. 37, caput, da Constituição Federal.

Com efeito, o parágrafo único do art. 4º do Decreto estatui o seguinte:

> "Art. 4º (...).
> Parágrafo único. Os instrumentos jurídicos negociais firmados no processo de alienação serão regidos pelos preceitos de direito privado."

O referido dispositivo viola diretamente o disposto no art. 37 da Constituição Federal, que assevera:

> "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: "

Sobre esse ponto, o Professor Gilberto Bercovici assevera (doc. 3):

> "(...)
> O objetivo essencial das sociedades de economia mista não é a obtenção de lucro, mas a implementação de políticas públicas. Segundo Fábio Konder Comparato, a legitimidade da ação do Estado como empresário (a iniciativa econômica pública do artigo 173 da Constituição de 1988) é a produção de bens e serviços que não podem ser obtidos de forma eficiente e justa no regime da exploração econômica privada. Não há nenhum sentido em o Estado procurar receitas por meio da exploração direta da atividade econômica. A esfera de atuação das sociedades de economia mista é a dos objetivos da política econômica, de estruturação de finalidades maiores, cuja instituição e funcionamento ultrapassam a racionalidade de um único ator individual (como a própria sociedade ou seus acionistas). A empresa estatal em geral, e a sociedade de economia mista em particular, não tem apenas finalidades microeconômicas, ou seja, estritamente 'empresariais', mas tem

> essencialmente objetivos macroeconômicos a atingir, como instrumento da atuação econômica do Estado.
>
> Estes dispositivos constitucionais são formas distintas de vinculação e conformação jurídica, constitucionalmente definidas, que vão além do disposto no artigo 173, §1º, II, que iguala o regime jurídico das empresas estatais prestadoras de atividade econômica em sentido estrito ao mesmo das empresas privadas em seus aspectos civil, comercial, trabalhista e tributário. A natureza jurídica de direito privado é um expediente técnico que não derroga o direito administrativo, sob pena de inviabilizar a empresa estatal como instrumento de atuação do Estado. (...)
>
> Fica evidente, assim, que o texto previsto no artigo 4º, parágrafo único do Decreto nº 9.188/2017, que determina que o regime jurídico do processo de alienação dos ativos das sociedades de economia mista é de direito privado, não tem qualquer fundamento constitucional. Trata-se de tentativa de fuga do regime de direito público aplicável por determinação constitucional a toda e qualquer sociedade de economia mista enquanto ente integrante da Administração Pública Indireta. (...)".

Ora, conquanto eventuais contratos no processo de alienação de ativos possam ser entabulados com investidores privados (nacionais ou estrangeiros), não se pode afastar, principalmente por intermédio de um Decreto autônomo, a incidência dos princípios regedores da administração pública nesses instrumentos, sob pena de se fragilizar, de modo inconstitucional, a própria defesa do patrimônio público e dos interesses da sociedade brasileira.

Assim, o dispositivo inquinado veicula grave inconstitucionalidade e deve ser afastado do ordenamento jurídico. É o que se requer.

## 7 – Violação aos princípios da Legalidade e da Moralidade escritos no art. 37, *caput*, da Constituição Federal.

Com efeito, o §1º, do art. 40 do Decreto inquinado estatui o seguinte:

> "Art. 40 (...).
>
> §1º Em relação aos procedimentos competitivos de alienação já concluídos anteriormente à data de publicação deste Decreto, caso exercida a faculdade de adesão prevista no art. 3º, §1º, ficam preservados os atos anteriormente praticados."

Objetivamente esse dispositivo destacado permite a "legalização" de todos os procedimentos administrativos de alienação de ativos das empresas estatais já realizados antes da publicação na norma inquinada, tenham ou não conformação com a lei e, principalmente, com a Constituição Federal.

Trata-se da legalização das ilegalidades e inconstitucionalidades já perpetradas pelo Poder Executivo na sua política de alienação de ativos das empresas estatais em curso no País, em clara ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, inscritos no *caput* do art. 37 da Constituição Federal, que se reitera:

> "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de **legalidade**, impessoalidade, **moralidade**, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: "

Ora, nem mesmo o princípio da segurança jurídica pode justificar a manutenção de um quadro de grave inconstitucionalidade como pretende o Decreto autônomo nesse ponto. Inaplicável também na espécie, a teoria do fato consumado, de modo que a Constituição brasileira não pode aceitar pacificamente a cristalização de uma realidade incompatível com suas normas e princípios.

Ademais, como adverte a doutrina:

> "Os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem às suas origens, invalidando as conseqüências passadas, presentes e futuras do ato anulado. E assim é porque o ato nulo (ou o inexistente) não gera direitos ou obrigações para as partes; não cria situações jurídicas definitivas; não admite convalidação" (MEIRELES, Hely Lopes).

## V – Do pedido liminar.

O provimento cautelar tem pressupostos específicos para sua concessão. São eles: o risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (*periculum in mora* e *fumus boni iuris*), que, presentes, determinam a necessidade da tutela cautelar e a inexorabilidade de sua concessão, para que se protejam aqueles bens ou direitos de modo a se garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional principal.

O *fumus boni iuris* significa a plausibilidade do direito alegado pela parte, isto é, a existência de uma pretensão que é provável, sendo possível ao juiz aferir esse determinado grau de probabilidade pela prova sumária carreada aos autos pelo autor do pedido cautelar.

O *periculum in mora* estará presente sempre que se verificar risco a que a demora do provimento jurisdicional definitivo, que aplicará o direito ao caso concreto submetido ao conhecimento do Poder Judiciário, seja danosa a esse mesmo resultado, na medida em que possa causar dano à efetividade do processo principal. Esse dano à efetividade do processo está ligado a outro dano, de natureza concreta, que pode ser, por exemplo, o perecimento do objeto da controvérsia.

Presentes esses dois requisitos, isto é, sendo provável o direito alegado e estando o mesmo sob ameaça, porque não é possível sua preservação até que o Poder Judiciário se pronuncie definitivamente naquele processo, está aberta a possibilidade do manejo da tutela cautelar.

No presente caso estão presentes ambos os requisitos, que podem ser delineados em apenas 2 assertivas:

a) O Decreto autônomo viola diversos dispositivos constitucionais; e

b) Se não sustada essa norma inconstitucional, diversas estatais (sociedades de economia mista) poderão ter seu patrimônio alienado, inclusive com a própria extinção material da Companhia, tornando praticamente irreversível essas decisões, com a concessão da medida judicial apenas ao final.

Afirma-se ainda, em complemento, que o "periculum in mora" reside na relevância da matéria e na impossibilidade de se tolerar que, por intermédio de um Decreto Autônomo, a Constituição Federal e o patrimônio público possam ser tão vulnerados, de modo que os demais Poderes do Estado fiquem à mercê das vicissitudes do Poder Executivo.

Trata-se de um documento (o Decreto Autônomo) que, embora ostente a condição de facilitador do processo de privatização das empresas estatais, acaba subordinando diversos direitos e princípios

constitucionais a esses interesses, o que não se compatibiliza com a Constituição Cidadã.

O "*periculum in mora*" também reside na flagrante inconstitucionalidade de se permitir que diversos dispositivos constitucionais sejam vulnerados, em detrimento de se buscar, a qualquer custo, a venda de ativos das sociedades de economia, inclusive promovendo sua extinção sem qualquer participação do Congresso Nacional.

A demora na apreciação do mérito e na declaração da inconstitucionalidade do Decreto, fatalmente acarretará prejuízos irreparáveis às empresas estatais e ao patrimônio público nacional, seja em função das alienações de patrimônio que poderão ser feitas, seja em função da convalidação ilegal das vendas já realizadas.

Diante desse quadro de graves inconstitucionalidades, impõe-se a suspensão liminar do Decreto nº 9.188, de 2017.

Nesse sentido, requer-se a concessão do provimento cautelar liminar para suspender a totalidade do Decreto Autônomo nº 9.188, de 2017, haja vista o referido dispositivo violar diversos dispositivos constitucionais, até final julgamento de mérito da presente ADI.

## VI – Do pedido final.

Posto isso, requer-se:

a) a concessão de medida liminar para suspender a vigência do Decreto inquinado (Decreto nº 9.188, de 1º de novembro de 2017).

b) o conhecimento e o processamento desta ADI para, ao final, ser julgada procedente e declarar-se a inconstitucionalidade do mesmo Decreto, pela configuração da violação aos diversos dispositivos constitucionais apontados;

c) a citação do Advogado Geral da União para vir defender, querendo, o diploma legal impugnado;

d) a oitiva do Procurador Geral da República para, segundo se espera, opinar favoravelmente à pretensão aqui deduzida;

e) A aplicação do princípio da fungibilidade, na eventualidade de entender cabível, na hipótese, não a ADI, mas a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF.

Requer-se prazo para juntada da procuração, nos termos da lei processual.

Dá-se à causa, o valor de R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Brasília (DF), 30 de novembro de 2017.

ALBERTO MOREIRA RODRIGUES
OAB/DF – 12.652

ENEIDA VINHAES BELLO DULTRA
OAB/BA - 13.993

SABRINA DURIGON MARQUES
OAB/SP - 253.024

GABRIEL DE CARVALHO SAMPAIO
OAB/SP - 252.259

DESIRÉE GONÇALVES DE SOUSA
OAB/DF - 51.483

BRENO BERGSON SANTOS
OAB/SE - 4.403